

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-024728.989.24-5.

Representante: Emmanuel Cais Burdmann.

Representada: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Responsáveis: Joaquim Lopes da Silva Junior (Secretário Adjunto de Infraestrutura Urbana à época); Caio Cesar Machado da Cunha (Prefeito à época).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar no âmbito da Concorrência Internacional n. 009-2/2024, Processo Administrativo n. 6.653/24, certame promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, objetivando a contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obras para implantação de novo sistema viário, com área de pavimento de aproximadamente 30 mil m², com serviços a serem executados de terraplenagem, sub-base, base, pavimento flexível, drenagem, passeios, ciclovias e sinalização viária, incluindo a construção de um viaduto sobre via férrea, com aproximadamente 2 mil m² e readequação de sistema viário em avenidas de alto tráfego, com área de pavimento de aproximadamente 7 mil m², como etapa do Programa Viva Mogi, a ser financiado parcialmente pela Corporação Andina de Fomento - CAF.

Valor Estimado: R\$ 87.720.632,51 (oitenta e sete milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Procuradora de Contas: Élide Graziane Pinto.

Advogados: Emmanuel Cais Burdmann (OAB/SP 450.865); Dalciani Felizardo (OAB/SP 299.287).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA VIÁRIO. REQUISIÇÃO DE GARANTIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS CONSORCIADAS.

FALTA DE JUSTIFICATIVA. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA INDEVIDA. REAJUSTE. DIVERGÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **EMMANUEL CAIS BURDMANN** contra Edital da Concorrência Internacional n. 009-2/2024, Processo Administrativo n. 6.653/24, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**, objetivando a contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obras para implantação de novo sistema viário, com área de pavimento de aproximadamente 30 mil m², com serviços a serem executados de terraplenagem, sub-base, base, pavimento flexível, drenagem, passeios, ciclovias e sinalização viária, incluindo a construção de um viaduto sobre via férrea, com aproximadamente 2 mil m² e readequação de sistema viário em avenidas de alto tráfego, com área de pavimento de aproximadamente 7 mil m², como etapa do Programa Viva Mogi, a ser financiado parcialmente pela Corporação Andina de Fomento - CAF.

1.2. O Representante se insurge contra os seguintes pontos do edital:

- a) Ofensa ao art. 42 da LC nº 101/01 pela possibilidade de ultrapassar o exercício financeiro, podendo atingir o prazo de cinco anos de execução.
- b) subitem 1.1 que visa a contratação em regime de empreitada semi-integrada, exigindo elaboração de projeto executivo.

Afirma que anteriormente a Prefeitura celebrou contrato com Paulo Oliveira Engenharia Ltda., no valor global de R\$ 3.387.351,24, decorrente da Concorrência Pública Internacional 12/23 (contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para gerenciamento, apoio

técnico, apoio à gestão de projetos e estudos necessários ao programa “MAIS MOGI”, a ser financiado parcialmente pela Corporação Andina de Fomento - CAF, incluindo tudo o mais que se fizer necessário para execução dos serviços e em conformidade com os requisitos previstos neste edital e seus anexos).

c) Defasagem das tabelas utilizadas na orçamentação

Assevera que as tabelas referenciais utilizadas para elaboração do orçamento são de janeiro (SIURB) e março (DER) de 2024.

d) Subitem 4.14, devido à exigência de envio da garantia da proposta juntamente com os documentos de habilitação.

d) limitação ao número de empresas para formação de consórcios.

e) Subitens 9.13.4 e 9.13.4.1, referentes à habilitação econômico-financeira, por exigirem certidão negativa de recuperação judicial e plano de recuperação judicial homologado.

Entende que as requisições extrapolam previsão da Lei nº 14.133/2024.

f) Subitem 9.14, quanto aos requisitos de capacidade técnica (CAT, Atestados e parcelas de maior relevância).

g) Subitem 16.2, que prevê prazo de três dias úteis para assinatura do contrato.

h) Cotação e reajuste de preços.

Afirma que o subitem 19.1 contraria o §3º do art. 92 da Lei nº 14.133/2021, quanto ao reajuste de preços.

Além disso, assevera que se trata de licitação internacional, mas os subitens 6.1.1. e 10.3 impossibilitam a cotação em moeda estrangeira.

i) Subitem 9.12. 3.3, que exige para fins de habilitação, apresentação de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, sem conferir a possibilidade de apresentação de certidão positiva com efeitos negativos.

Além disso, entende que há incompatibilidade da regularidade fiscal exigida com o objeto licitado.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.4. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, por decisão disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 12/12/2024, foi determinada a suspensão cautelar do procedimento impugnado e fixado o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES** para a apresentação de: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, bem assim o correspondente Estudo Técnico Preliminar; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências constantes da Representação.

1.6. A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte em sessão de 19/02/2025, ocasião em que as medidas adotadas em juízo preliminar foram referendadas.

1.7. Embora devidamente notificada, a Prefeitura de Mogi das Cruzes não apresentou justificativas.

1.8. Assessoria Técnica, por sua unidade de **Engenharia** manifestou-se pela **procedência parcial** das críticas direcionadas à sua área (evento 38.1).

1.9. Por seu turno, a unidade **Jurídica** da **Assessoria Técnica** posicionou-se pela **procedência parcial** dos questionamentos afetos à sua atuação (evento 38.5).

1.10. Chefia de ATJ, por sua vez, divergindo em alguns aspectos da **Assessoria Técnica**, concluiu pela **procedência parcial** da Representação (evento 38.6).

1.11. Ministério Público de Contas, no mesmo sentido, manifestou-se pela **procedência parcial** da Representação (evento 43).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 12/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-024728.989.24-5

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **EMMANUEL CAIS BURDMANN** contra Edital da Concorrência Internacional n. 009-2/2024, Processo Administrativo n. 6.653/24, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES**, objetivando a contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obras para implantação de novo sistema viário, com área de pavimento de aproximadamente 30 mil m², com serviços a serem executados de terraplenagem, sub-base, base, pavimento flexível, drenagem, passeios, ciclovias e sinalização viária, incluindo a construção de um viaduto sobre via férrea, com aproximadamente 2 mil m² e readequação de sistema viário em avenidas de alto tráfego, com área de pavimento de aproximadamente 7 mil m², como etapa do Programa Viva Mogi, a ser financiado parcialmente pela Corporação Andina de Fomento - CAF.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Por descumprir previsão legal¹, é procedente a crítica ao subitem 4.14, que exige apresentação de garantia da proposta juntamente com os documentos de habilitação.

Assim, deve a Administração da Municipalidade retificar o item criticado, deslocando a requisição da garantia da proposta para o momento da apresentação da proposta.

2.4. No que diz respeito ao questionamento à limitação ao número de empresas para formação de consórcios, também se mostra procedente, diante da falta de justificativa técnica para a limitação imposta, que caracteriza descumprimento ao §4º do art. 15, da Lei nº 14.133/2021².

Há constatação da Assessoria Técnica especializada, com base no memorial descritivo, de que “os serviços a serem executados são: terraplenagem, sub-base, base, pavimento flexível, drenagem, passeios, ciclovias, sinalização viária, construção de viaduto sobre via férrea e readequação de sistema viário em avenidas de alto tráfego, sendo que a coligação de várias empresas com expertises distintas poderá trazer economicidade a contratação”.

Neste sentido, a Prefeitura de Mogi das Cruzes deve excluir a limitação ao número de empresas para formação de consórcios, ou alternativamente, apresentar a devida justificativa técnica aprovada pela autoridade competente para referida limitação, nos termos legais.

2.5. Quanto à insurgência relativa ao prazo para assinatura do contrato, aliado às ponderações da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, considero procedente a crítica.

¹ Art. 58 da Lei nº 14.133/2021: “Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação”.

² “§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas.”

Desta forma, também neste aspecto o ato convocatório demanda revisão, devendo a Administração rever o item questionado, com a concessão de prazo razoável para assinatura do contrato.

2.6. No que se refere à exigência de certidão negativa de recuperação judicial, a crítica é procedente, conforme destacado pela Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica, haja vista a falta de previsão para a exigência.

De se observar que o art. 69, da Lei nº 14.133/2021, ao tratar dos requisitos de habilitação econômico-financeira, restringe a requisição de certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, senão vejamos:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

(...)

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

No mesmo sentido é a recente jurisprudência desta E. Corte, a exemplo das decisões adotadas nos julgados TC-014069.989.23-4, TC-001390.989.24-2, TC-018450.989.24-9 e TC-021736.989.24-5.

Desta forma, o item criticado deve ser excluído, conformando-se à previsão legal.

2.7. Demanda revisão também a data-base estipulada para reajustamento de preços, diante da divergência verificada entre os subitens 19.1, 19.2, 19.5 e 19.6, ora sendo considerada a data de apresentação da proposta, ora a data do orçamento.

Assim, a Administração deve compatibilizar os subitens criticados, conformando-se à previsão do §3º, do art. 92, da Lei nº 14.133/2021³, fixando índice de reajuste com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

2.8. No que se refere à defasagem das tabelas utilizadas para elaboração do orçamento, a crítica é parcialmente procedente, tendo em vista constatação da Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica de que a tabela Siurb (jan/24), era a mais recente até a publicação do instrumento convocatório, haja vista que a tabela Siurb posterior (julho/24), fora divulgada somente após a publicação do edital.

Alerta aquela Chefia que “se deve levar em conta, na análise da contemporaneidade ou defasagem da tabela SIURB, a data da sua efetiva divulgação, porque, não raro, há um atraso significativo em relação ao período de coleta dos dados pelo Órgão Gestor da fonte oficial de preços”.

Dessa forma, a Prefeitura de Mogi das Cruzes deve utilizar a última versão divulgada das tabelas oficiais usadas como fonte para a elaboração do orçamento.

2.9. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero as demais críticas improcedentes, a exemplo das insurgências relacionadas à requisição de registro dos atestados pelas entidades profissionais competentes, regularidade fiscal, ofensa ao art. 42 da LRF e ao art. 59, § 2º, da Lei 4.320/64, cotação da proposta em moeda nacional e alegação de que parte do objeto licitado já teria sido contratada.

Especialmente em relação às parcelas eleitas para comprovação da capacidade técnica, filio-me à posição adotada pela Chefia da ATJ, onde constatou que o item “revestimento de concreto asfáltico (sem transporte)” foi

³ § 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

parcialmente computado pela Assessoria, e considerada sua integralidade ultrapassa os 4% estipulados pelo § 1º do artigo 67 da Lei Federal no 14.133/2021, para ser considerado parcela de maior relevância.

2.5. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica, Chefia da ATJ e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: 1) deslocar a requisição da garantia da proposta para o momento da apresentação da proposta; 2) excluir a limitação ao número de empresas para formação de consórcios, ou alternativamente, apresentar a devida justificativa técnica aprovada pela autoridade competente para referida limitação, nos termos legais; 3) conceder prazo razoável para assinatura do contrato; 4) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial; 5) compatibilizar os subitens 19.1, 19.2, 19.5 e 19.6, fixando índice de reajuste com data-base vinculada à data do orçamento estimado; 6) utilizar a última versão divulgada das tabelas oficiais usadas como fonte para a elaboração do orçamento.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro